

1511675-80.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... pela mesma razão, o afastamento do tráfico privilegiado, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

A Defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal; a atenuante da confissão; a aplicação da causa de diminuição do instituto do tráfico privilegiado com a redução máxima; assim como a fixação de regime aberto com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511675-80.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511675-80.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON SILVA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

GILSON SILVA DOS SANTOS (RG 33504549-SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o art. 61, inciso II, alínea j do Código Penal, porque no 29 de maio de 2020, durante período de calamidade pública, por volta das 17h50, na Rua Adolfo Lazzari, altura do nº 133, Brasilândia, nesta cidade e comarca, estaria trazendo consigo 100 (cem) porções que continham 98,9 gramas de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, 850 (oitocentos e cinquenta) eppendorfs contendo 181,1 gramas de cocaína, 100 (cem) porções contendo 12,8 gramas da mesma droga sob a forma de crack e 19 (dezenove) frascos contendo 190 mililitros de tricloroetileno, com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 4/5) e sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 52/55). Após, foi concedida a liberdade provisória (fls. 98/101). O réu foi notificado/citado (fls. 116), apresentou defesa prévia (fls. 120/121) e a denúncia foi recebida (fls. 122).

Em julgamento de recurso em sentido estrito, deram provimento para revogar a

liberdade provisória (fls. 128/135).

Durante a primeira audiência de instrução foi ouvida uma testemunha policial. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com a majoração da pena base, em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes, e, pela mesma razão, o afastamento do tráfico privilegiado, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

A Defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal; a atenuante da confissão; a aplicação da causa de diminuição do instituto do tráfico privilegiado com a redução máxima; assim como a fixação de regime aberto com substituição por medidas restritivas de direito de praxe, e apelação em liberdade.

Determinou-se a juntada do laudo definitivo toxicológico e nova manifestação das partes. O Ministério Público reiterou a integralidade de suas alegações finais, requerendo o afastamento da tese de nulidade arguida pela Defesa, e a Defensoria pleiteou a absolvição do acusado em razão da ilicitude do laudo definitivo juntado aos autos, reiterando os debates orais apresentados em audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 7/10); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); laudo de constatação de substância (fls. 24/29); laudo definitivo toxicológico (fls. 263/266), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

Primeiramente, registre-se que a juntada do laudo definitivo das drogas após as alegações finais, embora fuja da melhor técnica, não está vedada, conforme se depreende do art. 231 do Código de Processo Penal. Verifica-se que o Ministério Público já tinha solicitado a vinda do laudo (fls. 3) e já havia determinação do juízo para que a diligência fosse cumprida (fls. 78 e 122), configurando-se mera irregularidade a juntada em duplicidade do laudo de constatação (fls. 84/88). Por fim, providenciada a juntada, deu-se a oportunidade para que as partes se manifestassem novamente, respeitando, pois, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, considerando-se que não houve qualquer prejuízo às partes, não há que se falar em nulidade processual e a absolvição do réu, em especial quando já havia nos autos um laudo preliminar atestando a natureza e a quantidade de droga apreendida.

O auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação de substância, agora confirmados pelo laudo químico-toxicológico, comprovam que as drogas apreendidas em posse do acusado eram: 100 (cem) porções que continham 98,9 gramas de tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, 850 (oitocentos e cinquenta) eppendorfs contendo 181,1 gramas de cocaína, 100 (cem) porções contendo 12,8 gramas da mesma droga sob a forma de crack e 19 (dezenove) frascos contendo 190 mililitros de tricloroetileno.

O policiais militares Fernando Nascimento de Gois Santos e Lucas de Souza Andrade, em sede policial, afirmaram que na data dos fatos, realizavam patrulhamento pela Rua Adolfo Lazzari, altura do numeral 133, quando avistaram um rapaz, que carregava uma sacola cor verde com um volume grande, e que este, ao notar a aproximação da viatura, deixou-a cair, mas foi abordado, revistado e identificado como sendo o réu. Narram que após efetuar buscas ao corpo dele, havia um celular no bolso da calça e a quantia de R\$ 8,60 (oito reais, sessenta centavos) no bolso traseiro. Contaram que, na tal sacola, havia substâncias devidamente embaladas e prontas para venda, sendo: cem porções de substância esverdeada aparentando ser maconha; oitocentos e cinquenta capsulas plásticas envoltas em plástico amarelo contendo pó branco semelhante à cocaína; cem pedrinhas amareladas análoga a "crack"; e dezenove vidrinhos contendo líquido incolor aparentando ser lança perfume. Contam que o réu, indagado, teria admitido ser traficante, e que sua função era carregar sacolas com drogas de um local indeterminado, até o local dos fatos, próximo a um "trailler". Disseram que, indagado sobre quanto ganha por dia, para realizar tal função, o acusado respondeu, que ganharia R\$ 30,00 (trinta reais) por cada sacola transportada, e que era a quinta vez por dia, e hoje era o primeiro transporte do dia.

Em juízo, a testemunha Lucas de Souza Andrade narrou que estava em patrulhamento na

rua, que é sem saída, e visualizou o indivíduo com uma sacola na mão, que, ao ver a viatura, se assustou e jogou a sacola no chão, razão pela qual foi abordado. Disse que na sacola foram encontradas as drogas, e o réu confessou que estava levando a droga até aquele local para redistribuição, e que era a 5ª vez que fazia aquilo. Informou que o réu soltou a sacola e deu um ou dois passos antes da abordagem. Não se recordou se havia transeuntes. Informou que havia lança perfume, cocaína, crack e maconha na sacola.

Em juízo, a testemunha Fernando Nascimento de Gois Santos narrou que estava em patrulhamento pela região, momento em que o motorista entrou numa rua sem saída e, após descer da viatura, viu uma pessoa descendo o escadão, no final da rua, e esse indivíduo, ao ver a polícia, soltou uma sacola no chão e deu alguns passos, o que chamou a sua atenção. Disse que encontraram drogas na sacola e o réu teria confessado que já tinha feito o serviço de levar a sacola até aquele local em outras ocasiões. Informou que eram drogas diversas e em quantidade substancial. Disse que não havia mais pessoas no local e que foi o sargento Lucas quem pegou a sacola.

O réu, GILSON SILVA DOS SANTOS, em seu interrogatório extrajudicial, disse que nesta data, por volta das 18h, estava caminhando pela Rua Adolfo Lazzari, quando de repente policiais militares da Rota chegaram no local e o mandaram parar, ordem esta que obedeceu. Disse que carregava uma sacola com drogas com maconha, cocaína e lança perfume e que estava fazendo o transporte daquelas drogas do bairro de Taipas para o Jd. Princesa. Afirmou que foi a quinta vez que estava fazendo esse trabalho de "mula", levando as drogas de um bairro ao outro. Narrou que não vendia as drogas, somente transportava de um lugar ao outro e que aceitou "fazer essas viagens" porque está desempregado e que fazia apenas uma viagem por semana ganhando o valor de R\$ 30,00 por cada sacola que levava. Nega ter tentado correr dos policiais, bem como não resistiu à prisão. Em seu poder foi localizado também seu aparelho celular e a quantia de R\$ 12,00 que nega ser oriundo do tráfico de drogas. Em juízo, o réu disse que estava em dificuldade financeira e uma pessoa lhe ofereceu um dinheiro, na quantia de R\$ 30,00, para levar aquela encomenda a um certo lugar, e ele aceitou sabendo que era uma coisa ilícita, mas não sabia sobre a quantidade. Informou que era a primeira vez que fazia aquilo.

A quantidade de drogas apreendida não demonstra que se trata de usuário, especialmente atrelada ao encontro de dinheiro em espécie. O réu, em seu interrogatório, não nega a posse dos referidos entorpecentes e ainda confessa que os transportava, em atividade equiparável à traficância segundo o rol das condutas do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Importante aduzir que o depoimento dos policiais foi coeso, não existindo qualquer indício de que a fala dos agentes, os quais gozam de fé pública, seria para prejudicar a pessoa do réu, mas somente um relato dos fatos ocorridos. Nada demonstra que os agentes públicos quisessem prejudicar o réu, contando evento inexistente.

Por fim, a confissão do réu, espontânea, tanto durante a abordagem quanto em seu interrogatório extrajudicial, confirma a autoria do crime.

Portanto, de rigor a condenação do réu.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena-base para o crime de tráfico de entorpecentes acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso, em razão da variedade das drogas apreendidas, observando-se o art. 42 da Lei 11.343/06.

A agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "naufrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "naufrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "naufrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer

calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor e/ou demonstre certa fragilidade da vítima quando da conduta, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavirus disease 19 – COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica ou não ficou demonstrado que a vítima estava numa situação mais vulnerável em decorrência da pandemia. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afasto a agravante mencionada pelo Ministério Público na peça vestibular. Presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para 5 anos, considerando-se que é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, ante a primariedade do réu e o distanciamento da habitualidade delitiva, a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é cabível, sendo conferida ao réu a diminuição na fração de 2/3 da pena.

Então, a pena definitiva será de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

O réu deverá cumprir a pena em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, inciso c, do Código Penal.

Viável a substituição da pena por restritiva de direitos ao acusado, tendo em vista a primariedade do réu e o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu GILSON SILVA DOS SANTOS (RG 33504549-SP) como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade deverá ser substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da reclusão e pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo destinado a entidade pública ou privada com destinação social.

O réu poderá recorrer em liberdade, ante a quantidade de pena cominada, a fixação de regime aberto, além da própria substituição da pena privativa.

Oficie-se para destruição das drogas apreendidas.

Decreto o perdimento do valor e dos objetos apreendidos em favor da União, por se tratar de bem proveniente da prática de tráfico, de acordo com o art. 63 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

São Paulo, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA